

刑法
No22

H27-1

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 不真正不作為犯の作為義務は、法律上の規定に基づかなければならない。

イ. 不真正不作為犯が成立するために、作為可能性を必要としない場合もある。

ウ. 不真正不作為犯の因果関係が認められるためには、期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったことが必要である。

エ. 不真正不作為犯は、殺人罪や放火罪については成立するが、財産犯については成立しない。

オ. 不作為による放火罪が成立するためには、既発の火力を利用する意思は必ずしも必要ではない。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. ウ オ

No22

H27-1

不真正不作為犯

正解

5

正答率

89%

ア 誤っている

最決平 17.7.4 (百選 I 6 事件)。判例は、「被告人は、自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた上、患者が運び込まれたホテルにおいて、被告人を信奉する患者の親族から、重篤な患者に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあったものと認められる。その際、被告人は、患者の重篤な状態を認識し、これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきである」としており、先行行為、保護の引受け及び排他的支配を根拠として作為義務を認めている。よって、不真正不作為犯の作為義務は、法律上の規定に基づかなければならないわけではない。

イ 誤っている

不真正不作為犯が成立するためには、作為義務の他に作為の可能性・容易性が認められることが必要であると解されている。作為可能性が必要とされるのは、作為をなし得ない場合にも作為を要求することは無意味であるし、作為をなし得ないにもかかわらず作為をしなかったとして処罰することは不当だからである。

ウ 正しい

最決平元.12.15 (百選 I 4 事件)。判例は、「直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女が年若く(当時 13 年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と午前 2 時 15 分ころから午前 4 時ころまでの間に同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係があると認めるのが相当である」としている。このように不真正不作為犯の因果関係が認められるためには、期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが合理的な疑いを超える程度に確実であることが必要となる。

エ 誤っている

最決平 15.3.12 (百選 II 52 事件)。判例は、「誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐偽罪の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるといふべきであるから、錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する」としている。その理由として、判例は、「受取人においても、銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として、自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される」ということなどを挙げている。このように判例は、誤振込みがあったにもかかわらず、そのことを秘して払戻しを受けた場合に、告知義務違反という不作為による欺罔行為があるとして、詐欺罪の成立を認めている。よって、財産犯についても不真正不作為犯が成立することがある。

オ 正しい

最判昭 33.9.9 (百選 I 5 事件)。判例は、「被告人は自己の過失により右原符、木机等の物件が焼燬されつつあるのを現場において目撃しながら、その既発の火力により右建物も焼燬せられるべきことを認容する意思をもつてあえて被告人の義務である必要かつ容易な消火措置をとらない不作為により建物についての放火行為をなし、よつてこれを焼燬したものである」として放火罪の成立を認めている。このように、判例においては既発の火力を利用する意思は必要とされていない。